



מדינת ישראל

משרד המשפטים

המפקחת על רישום המקרקעין פתח תקוה

1

מס' תיק: 49/09+79/09

התובעים:

1. עסיה אליהו ת.ז. 4765353

2. עסיה דינה ת.ז. 4142005

ע"י עוה"ד ורד שניאור

מרח' נחמיה 5א', כפר סבא

"הנתבעים שכנגד"

- נ ג ד -

הנתבע:

יהורם חיים ת.ז. 058880972

ע"י ב"כ עוה"ד עמית קפלן

מרח' התע"ש 20, כפר סבא

"התובע שכנגד"

1

2

3

4

פסק - דין

1. התובעים, הנתבעים שכנגד, בעלי זכויות בדירה בבית ברחוב קורצ'אק 18 בכפר סבא,

מקרקעין הידועים כחלקה 260 בגוש 7621 (להלן-"הבית").

הנתבע, התובע שכנגד, בעל זכויות בדירה הצמודה לה בבית.

5

6

7

8

2. התובענה העיקרית הינה להורות לנתבע להשיב לתובעים שטח של 43 מ"ר במקום

המסומן במפת המדידה של המודד מטעמם והמסומן באות "ז" או כל שטח מוסכם

אחר שיוצע בשטח זהה וגידור השטח להבטחת השימוש הבלעדי והייחודי של

התובעים בשטח זה;

להורות לנתבע להימנע מלעשות שימוש ברכוש המשותף, ולנהוג בו מנהג בעלים ללא

הסכמה מראש ובכתב מאת התובעים ולהימנע מעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע

בזכות הקניין של התובעים ברכוש המשותף.

לחילופין, התבקש, כי תוגש חוות דעת שמאית לפיה ישום השמאי את השימוש ביתר

9

10

11

12

13

14

15

16

שעושה הנתבע על חשבון התובעים.	1
כן התבקש, כי יאושר כי אין כל מניעה להגיש נגד הנתבע תביעה לפיצוי כספי ו/או	2
תשלום דמי שימוש ראויים על השימוש שעושה ועשה הנתבע ברכוש המשותף ללא	3
הסכמתם.	4
	5
3. התובענה שכנגד הינה תביעה כספית לחיובם של הנתבעים שכנגד בתשלום מחצית	6
עלות הגדר המשותפת המפרידה בין 2 החצרות, שהוקמה לטענת התובע שכנגד	7
בהסכמתם ולאחר שהוסט קו הגדר לפי דרישתם.	8
	9
4. התובעים, הנתבעים שכנגד, ה"ה עסיה (להלן-"עסיה") טענו בתמצית, כי הינם	10
פנסיונרים, החיים על קצבת זקנה, וכי הם הבעלים של דירה בבית הדו- משפחתי.	11
הרכוש המשותף של הבית כולל חצר בשטח של 711 מ"ר.	12
התובעים רשומים כבעלי הזכויות במחצית מהרכוש המשותף ואולם, הנתבע, מחזיק	13
ועושה שימוש ייחודי ובלעדי בשטח הגדול מ-50% מן הרכוש המשותף, שטח של כ-	14
398.5 מ"ר, בעוד התובעים עושים שימוש ייחודי השטח של 312.5 מ"ר.	15
חזקה ייחודית זו ברכוש המשותף, מעבר לחלקו הרשום של הנתבע, נעשתה ונעשית	16
לדבריהם ללא הסכמה והרשאה מהם ואף על יסוד הטעיה מכוונת של התובעים	17
והשגת הסכמתם בעורמה.	18
לטענתם מעולם לא מדדו את שטח המגרש ואת החלק המוחזק על ידם ו/או על ידי	19
שכניהם ברכוש המשותף, שכן כל הבקשות שהוגשו על ידם לצורך קבלת היתרי בניה	20
על המגרש היו בתקופה שקדמה לחובת ביצוע מדידה על ידי מודד מוסמך של המגרש	21
עליו מבוקשת הבניה.	22
ביום 23.5.2000 לאחר שרכש הנתבע את הזכויות בדירה הגיש לרשות בקשה למתן	23
היתר בניה ובמסגרתה ביצע מדידה של המגרש.	24
הנתבע ביקש מהתובעים לחתום על הבקשה שהגיש, לפי דרישת הוועדה המקומית	25
ורשות הרישוי המקומית, ברם, לא העמיד אותם טרם חתימתם על העובדה	26
שהתבררה לו אגב המדידה כי הוא מחזיק בחלק גדול בהרבה מהחלק המוחזק על	27
ידם ברכוש המשותף. לטענתם הנתבע העלים מהם מידע זה והחתים אותם על	28
תוכניות ההגשה במרמה. לדבריהם הנתבע אף הסכים להשיב להם חלק מן השטח	29
אך ורק על מנת להשיג מהם את החתימה על הבקשה.	30
פרטי התובענה נודעו לתובעים לראשונה מייד לאחר שהוגשה נגדם תביעה לסילוק יד	31
ולדמי שימוש ראויים לבית המשפט המחוזי בפתח- תקווה ת.א 3240-07/08. על ידי	32
השכן בחלקה הגובלת (הירש), בטענה כי הם מחזיקים בשטח השייך לו.	33
תיק התביעה הסתיים בהסכם פשרה שנחתם בין התובעים לבין השכן, כאשר השיבו	34
לחזקתו את החלק הארי של אותו שטח. לדבריהם הסכמה זו נבעה ממדידת המגרש	35

על ידי מודד מוסמך מטעמם , כאשר אגב המדידה התברר להם כי הנתבע מחזיק	1
בשטח גדול יותר כמתואר.	2
הסכם הפשרה קיבל תוקף של פס"ד ביום 9.12.08.	3
אשר לתביעה שכנגד נטען, כי הנתבע לא ביקש מהתובעים לחתום על בקשה להקמת	4
גדר, והם לא חתמו על בקשה כזו. לאחר קבלת ההיתרים הקים הנתבע את הגדר על	5
דעת עצמו.	6
	7
5. טענות הנתבע, התובע שכנגד בתמצית-	8
הנתבע, רכש את זכויותיו בבית בשנת 1999 מידי ה"ה, מליחי, מי שהיה בעל הזכויות	9
בבית במשך עשרות בשנים ומי שהתגורר בשכנות עשרות בשנים עם	10
התובעים/הנתבעים שכנגד.	11
במשך למעלה מ- 50 שנה הפרידה גדר רשת בין שני הבתים וקבעה את הגבול בינם,	12
בהתאם לתשריט שצורף כנספח א' לכתב ההגנה והתביעה שכנגד. גם כאשר הגישו	13
התובעים בקשות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה עוד בשנת 1964, ציינו בתשריט	14
מטעמם את מיקום קו הגבול ההיסטורי. בבקשה להיתר בניה שהגיש הנתבע סומנה	15
אותה הגדר כקו הגבול המפריד בין החצרות.	16
תובע 1 סירב לתת הסכמה לבקשה להיתר אלא אם יקבל שטח מן הקרקע. הנתבע	17
הציע לתובעים כי יסמנו קטע אדמה בחלק האחורי ובמידת האפשר יסכים וימלא	18
אחר מבוקשם/דרישתם. לטענתו התובעים הסכימו וכבר ביום למחרת, סימנו את	19
שטח האדמה כרצונם וקבעו גדר חדשה בחלק המסומן על ידם תוך שהינם משנים	20
את תוואי הגדר הקיימת. לדבריו, מיד לאחר קבלת הסכמת התובעים וקביעת קו	21
הגבול החדש ע"י התובעים בעצמם חתמו התובעים בהסכמתם החופשית ומדעת על	22
הבקשה להיתר. לדבריו, עוד בשנת 2000, ידעו התובעים כי שטח חצרו של הבית גדול	23
באופן יחסי משטח חצר ביתם ואף דרשו וקיבלו מהנתבע חלק משטח חצר הבית	24
שסופח לחצר ביתם כאמור. לפיכך, משהסכימו וחתמו על הבקשה להיתר וקיבלו	25
כתנאי לחתימתם על הבקשה את הקרקע אין להם מה לטעון בהקשר זה.	26
הנתבע יטען, כי מרגע שקיבלו התובעים דרישה מצד השכן ממזרח להשבת שטח	27
אדמה ולאחר שהוגשה נגדם תביעה על ידו בעניין, החליטו "לעשות חשבון" עם	28
הנתבע.	29
לדבריו בביקור ניתן היה להתרשם בעין, כי הפרשי הגבהים בין החצרות מראים, כי	30
לא ניתן להורות על העברת שטח מצד זה לזה ויש לדחות בקשה זו על הסף.	31
אשר לתביעה שכנגד נטען, כי לאחר חתימת התובעים על הבקשה להיתר ובטרם החל	32
הנתבע בבנייה, סוכם בין הנתבע לתובע מס' 1 כי הגדר מאבן אשר תוקם בין	33
החצרות ישאו בה הצדדים בחלקים שווים. הנתבע הוא זה שמימן את עלותה של	34
הגדר שבנה בין שתי החצרות. ואולם, בסיום בניית הגדר, כאשר ביקש הנתבע	35

- מהתובעים לשלם את מחצית העלות חזרו בהם התובעים מהסכמתם וסירבו לשלם. על אף התנגדות התובעים, כביכול, לבניית הגדר לא טרחו לא בעת בנייתה ואף לא לאחריה לשלוח לנתבע כל הודעה ולא נקטו בכל פעולה "נדרשת" וסבירה כדי למנוע מהנתבע לבנות חומה שנבנתה שלא בהסכמתם ובניגוד לרצונם כביכול. לא עלה בידו להמציא אסמכתאות חשבוניות לעלות הגדר. עד כאן טענות הצדדים.
- 7
6. ביסוד התביעה העיקרית והתביעה שכנגד שאלת תוואי הגבול המשותף החוצה את החצר המשותפת לשתיים לשימושם הייחודי של התובעים ושל הנתבע.
- 10
7. **סטטוס הגדר המשותפת-**
- מעיון בנסח הרישום נראה, כי מדובר בבית משותף דו משפחתי, שנרשם על פי שטר 926/56.
- 14 אין למי מהצדדים צמידויות כלשהן והשטח שסביב לדירות הינו רכוש משותף, אשר לכל צד על פי צו רישום הבית המשותף מחצית הימנו.
- 16
8. בסעיף 52 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 הוגדר בין היתר "רכוש משותף" - "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת".
- 22
9. בהקשר זה נפסק, בין היתר, ברע"א 698/85 יהודה בן צור נ' נעים ששון, תק-על 732, 735 (2), 1987, לאמור: "המבחן על-פי הגדרה זו להיות הרכוש "רכוש משותף", הוא מבחן היעוד בלבד. במלים אחרות, חלקיו של ה"רכוש המשותף", כפי ששמו מעיד עליו, הם חלקי הבית המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם. אולם נוכח מסקנתנו כי זכויותיהם של "בעלי" הדירות ב"רכוש המשותף" אינן נקבעות על-פי החוק, אין מנוס מלתת למבחן הייעוד משמעות כפולה. האחת, כי אותם חלקי הבית מיועדים על-פי מהותם לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם. והמשמעות האחרת כי בידי כל בעלי הדירות או מרביתם, זכות לעשות שימוש בחלק או בחלקים אלה של הבית, שהוענקה להם על-ידי מי שבכוחו להעניק זכות כזאת. ביחסים ההדדיים שבין "בעלי" הדירות לבין עצמם לצורך ניהולו של ה"רכוש המשותף", מושם הדגש כולו על עצם זכותם להשתמש ברכוש בצוותא חדא. מכאן שאין נפקא מינה לשם החלת הוראותיו של התקנון המצוי אם הזכות

של "בעלי" הדירות להשתמש ב"רכוש משותף" נובעת מרשות גרידא שניתנה להם, או מכח היותם בעלי זכות קניינית ברכוש זה. ובלבד, כאמור, שהזכות לשימוש בחלק זה של ה"רכוש המשותף" מצויה בידם".	1
	2
	3
	4
10. תוואי הגדר בין הדירות המחלקת כאמור את החצר המשותפת לשניים הוא רכוש משותף, ממש כשם שהחצרות עצמן הן רכוש משותף.	5
	6
בפועל נוהגים הצדדים באותן חצרות כחלקים צמודים לכל דבר ועניין. החצרות תחומות בגדר, ביניהן גדר המחלוקת, כל צד טוען לשימוש ייחודי בחלק מסוים במקרקעין והצדדים אינם מעוניינים ממילא בברירת המחדל הקניינית בהקשר זה.	7
	8
הם מבקשים לראות בעצם החלוקה כהסכמה על חלוקת שימוש המותרת לידם לפי דין.	9
	10
הן התובעים והן הנתבע ציטטו את ההלכה הרווחת לפיה בעלי דירות בבית משותף יכולים להסכים בעל פה על ייחוד השימוש ברכוש המשותף לחלק מבעלי הדירות והסכמה כזאת אינה בגדר עסקה במקרקעין הטעונה כתב (ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78).	11
	12
	13
	14
	15
	16
11. ואולם, התובעים עומדים על זכותם לשימוש יחודי בדיוק ב-50% מן השטח המשותף אף שבפועל חלק זה מעולם לא הוחזק על ידם.	17
	18
העובדות במקרה דנן כמעט ואינן שנויות במחלוקת. עמדתי על מרביתן בביקור במקום בנוכחות הצדדים והתרשמתי כי לדירות קיר משותף אשר בסמוך לקו החיבור הגדר הבנויה.	19
	20
	21
עפ"י עדויות הצדדים על תוואי זה – למעט השינוי שחל בתוואי ביוזמת הנתבע כמתואר להלן- הוצבה גדר רשת במשך עשרות שנים.	22
	23
התובעים טענו, כי הם חיים 48 שנים באותה דירה ולא היתה להם כל טרזניה בקשר לתוואי הגדר אז. בתוואי הגדר נערכו כאמור שינויים קלים עובר לחתימת התובעים על היתר הבניה, פרט לשינוי זה השתמר איפוא קו הגדר מזה עשרות שנים.	24
	25
	26
	27
12. נראה, כי ספק אם היתה מוגשת התביעה שבנדון אלמלא תוצאתו של ההליך בת.א. 3240/07 בבית המשפט המחוזי בפתח תקוה בעניין גילי הירש נ' עסיה אליהו ועסיה דינה. באותו הליך נתבעו התובעים דנן, עסיה, ע"י שכניהם מן החלקה הסמוכה, הירש, לסלק ידם משטח המצוי בחצר המוחזקת על ידם, ואשר על פי הנטען שייד לחלקת התובעים-הירש.	28
	29
	30
	31
	32
הנתבע דנן לא היה צד להליך זה, אשר הסתיים במתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין הצדדים לפיו הוסט קו הגבול בין החלקות בהסכמה אל השטח המוחזק ע"י התובעים דנן. שינוי תוואי הגבול בין החלקות גרע ממילא שטח מן החצר	33
	34
	35

- 1 המוחזקת ע"י עסיה, אותו שטח נראה בברור בתשריט שצורף להסכם הפשרה
2 האמור.
3
- 4 13. עפ"י עדותם של עסיה עם הגשת כתב התביעה בבית המשפט המחוזי הם שכרו מודד
5 מוסמך ואזי התברר להם כי יש ממש בתביעה הירש וכן כי אף הם זכאים לתוספת
6 שטח שכן השטח המוחזק על ידם- בחלקה שבנדון- קטן ב-43 מ"ר מהחלק המוחזק
7 ע"י הנתבע.
8 בהקשר זה השיב התובע בחקירתו הנגדית לאמור:
9 " ש. איך נודע לך בפעם הראשונה היקף האחזקה, שיש לו שטח גדול יותר?
10 ת. אני לא ידעתי בכלל שמגיע לי עד שבה השכן שמצד מזרח, אמר שמגיע לו אדמה
11 ממני, זה היה לפני שנתיים. אם אני לא ייתן לו הוא יפנה לעו"ד. מסרתי לעו"ד
12 שלי והיא שלחה מודד ומדדה הכל וראינו שזה מגיע לו מאז נודע לפי המדידה
13 שהשכן השני מצד מערב מחזיק ב-90 מטר יותר ממה שאנחנו, את זה הוא צריך
14 להחזיר".
15
14. כבר בשלב זה יוער, כי טענה זו בנסיבות המתוארות ראוי ליתן לה משקל. מדובר
בשכונה ותיקה הבנויה בתים דו משפחתיים צמודי קיר הבנויים על חלקה אחת.
לאורך הרחוב צמודות החלקות ממילא אלה לאלה.
תיאורטית יתכן "אפקט דומינו" לפיו ביצוע מדידה עדכנית של שטחי החלקות ילמד
על תזוזת גבול חלקה, בעל אותה חלקה יבקש לפעול בדרך בה פעלו התובעים יבצע
מדידה של החלקה שלו ויעתור לחלוקה מחדש של הזכויות בינו לבין שכנו, הגם שבין
הבתים קיים מזה עשרות שנים קו גבול ברור, צמוד על פי רב לקו החיבור בין
הדירות הצמודות. חלוקת הזכויות בדרך זו מִשְׁלַל היו זכויות בחלק מסוים במקרקעין
אינו מתיישב אף עם הנתונים הפיזיים, שכן אם בתזוזת גבול בין חלקות מדובר
בפינוי מחסן והריסת שביל בתזוזת קו גבול בין דירות באותה חלקה מדובר בהריסת
חלקים מובנים בדירות או בכניסה פיזית לתחום הצמוד לדירה במקרה זה לפתח
הוטרינה בסלון דירת הנתבעים או בפתח הדלת בדירתם. מציאות זה מחייבת מתן
משקל להסכמה המתמשכת בין בעלי הזכויות בחלקה לחלוקה שנעשתה "דה
פאקטו" לאורך השנים ומתן משקל לעקרון תום הלב בנסיבות המתוארות.
15. מן הכלל אל הפרט התובעים עצמם, עפ"י עדותם, ייסדו את קו גדר הרשת בינם לבין
מליחי, מי שמכר זכויותיו לנתבע. התובעים לא התנגדו לחלוקה אדרבא הם טוענים
אף היום לזכותם לשימוש ייחודי במרבית השטח, הם נוהגים בשטח מנהג בעלים,
בחצר הונחו מתקנים שונים ואיש אינו רשאי להיכנס לחצר המוחזקת על ידם שלא
בהסכמתם.

אמנם מצב דברים שבו תופס בעל דירה חזקה בחלק חצר הבית המשותפת, מבלי שהזכויות הוגדרו בחוזה העברת זכויות מפורש, ניתן להיחזות כמצב של רשות. משלא הוכח שניתנה תמורה, עסקינן בהרשאת חינוס, לגביה נפסק כי ניתן לבטלה, עם גילויה של התנגדות מצד בעל דירה אחר, שאף לו חלק בחצר המשותפת. (ר' גם פרופ' מיגל דויטש "קניין" כרך ב' עמוד 414 וכן רע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נ. משה סלומון ואח', תק-על 99 (4), תשנ"ט - תש"ס 1999).

ואולם, בע"א (תל אביב - יפו) 2816/03 ציפורה קונצ'יצקי ואח' נ. דליה שפלן ואח' תק-מח 2006 (2), 991, נדון ערעור על החלטת המפקחת על רישום המקרקעין בתביעה כנגד המשיבים, שהשתלטו על מחצית הגג_שהוא רכוש משותף שמעל דירת המערערים בתקופה של למעלה מ-40 שנים. בפסק הדין, נקבע, בין היתר, לאמור: **"על פי ההלכה הפסוקה, רק במקרים נדירים שבהם הוענקה לבעלי הרישיון גם הרשות לבנות ובהסתמך על מתן רישיון לצמיתות השקיעו בעלי הרישיון במקרקעין, הכירו בתי המשפט בטענה בדבר אי הדירותה של הרשות. הטעם לכך הוא הגנה על הצפייה הלגיטימית של בעלי הרישיון בדבר זכותם במקרקעין והסתמכותם על קיומה".**

16. במקרה דנן מבקשים כאמור התובעים לבטל הסכמתם לשימוש באותו חלק יחסי, מן הטעם שהוטעו ע"י הנתבע. לטענת התובע רק לאחר המדידה שבוצעה על ידו נודע לו כי הוטעה ע"י הנתבע כאשר זה פנה אליו בבקשה ליתן הסכמתו לבניה שבוצעה על ידו בשנת 2000. על נסיבות ההטעה הנתבעת העידו הצדדים.

17. כבר בשלב זה יוער, כי אכן סעיף 15 לחוק החוזים מעניק ברירת ביטול למי שמתקשר בחוזה עקב הטעייה ע"י הצד השני או מטעמו של הצד השני. ברירה זו מוענקת בצורה רחבה ביותר. היא עומדת לצד שהוטעה בין אם היתה הטעיה במרמה, בין אם ניתנה ברשלנות או אף בתום לב וללא רשלנות (ראה פרופ' פרידמן, חוזים, חלק ב', 784, 806). ואולם, במקרה דנן לא היה בידי הנתבע מידע שלא היה מצוי או יכול היה להיות בידי התובעים עצמם. מדידת השטח היא פעולה פשוטה שהתובעים יכלו לבצע ואכן ביצעו מאוחר יותר. מדידה שכזו יכלה אף להתבצע על ידם עובר למתן ההסכמה לתוואי החדש כפי שיפורט להלן. לפיכך, לא מצאתי יסוד בדין לטענת ההטעה.

18. היתה או לא היתה הסכמה?

אין מחלוקת כי בסמוך למועד רכישת הדירה ע"י הנתבע ביקש הלה להרחיבה ופנה לשם כך לקבלת היתר בניה כדין. בהקשר זה העיד עסיה בחקירתו לאמור:

"ש. אתה אומר שעד שנת 2008 לא ידעת שאתה יושב על חלקה של השכן ממזרח ("הירש" ט.ל) וחשבת כל השנים שאתה יושב על חצי ומליחי על חצי.	
ת. נכון	1
ש. למה בשנת 2000 לקחו חלק מהגדר והזיזו לשטח של התובע.	2
ת. זה מה שנתן, אני הסברתי את זה, שהוא בא וביקש לחתום על ההיתר הוא אמר	3
שהגדר הולך עקום בכיוון אחורה, אמר שלא נותנים לו לבנות עד שהגדר תהיה ישרה.	4
אז הוא נכנס פנימה 3 מטר ופיצה אותי. אני מראה בשרטוט את הקו הירוק שהוא קו	5
הגבול העקום שהיה. אבקש לצרף	6
---	7
ש. אני אומר לך שמי שהסית את הגדר זה היית אתה.	8
ת. אני לא, הוא הסביר לי.	9
ש. מי הזיז.	10
ת. זה באישור שלו. רשת לא הזזתי. הוא היה שמה ואני הייתי שם. הוא אמר זה מה	11
שמגיע לך, זה מה שמגיע לי, לא רציתי לריב איתו.	12
ש. מה שאתה אומר שמשנת 2000 רק אז אתה יושב חצי חצי אחרי שתיקנת את הקו	13
הירוק.	14
ת. זה שהוא בא ואמר שלא נותנים לו לבנות". (ר' פרוטוקול הדיון מיום 19.10.09 בעמ'	15
6-7).	16
	17
19. לטענת הנתבע שינוי תוואי הגבול בין הדירות נעשה לפי דרישת התובע דווקא	18
בהקשר זה השיב בחקירתו לאמור :	19
"ת. רכשתי בשנת 1999 ממליחי יחיא שהוא יורש המנוחה צביה. לאחר מכן הוצאתי	20
תוכניות בניה. כשקניתי היה חדר וחצי וגדר רשת שעוברת בקו ישר מאוזן בשני צידי	21
הבית. בבית היה שיפוע חזק כל הרחוב הולך בשיפוע מצד מערב לצד מזרח.	22
הוצאתי תוכניות בניה והתבקשתי להחתים את השכנים על התוכניות פניתי לכולם	23
כשפניתי למר עסיה הוא סירב בכל תוקף קילל אותי וגירש אותי אמר לי שלא ייתן לי כי	24
הוא צריך לקבל ממני אדמה. אני לא בקיא באדמות קניתי את הבית רציתי לבנות מתוך	25
רצון לשכנות טובה אמרתי לו תסמן קטע מאחורנית במידת האפשר ואני ייתן לך. הוא	26
והבן שלו עמי שהיה גר איתו באותה תקופה למחרת על הבוקר תקעו את הגדר איפה	27
שרצו בצורת ריש. כמובן שלאחר הסכמה שלי אבל הם שמו איפה שרצו אם היו לוקחים	28
מטר קדימה הייתי נאלץ להסכים. הוא לחץ לי יד והתלהב שלקח לי אדמה הכניסו אותי	29
לסלון וחתמו לי על התוכניות. מפה התחיל המסע.	30
---	31
ש. במקום גדר הרשת אתה בנית גדר אחרת	32

1. ת. נכון	1
2. ש. איפה מיקמת אותה	2
3. ת. איפה שהיתה גדר הרשת	3
---	4
5. ש. התובע טען שהשינוי בתוואי הגדר נעשה לבקשתך לצורך קבלת היתר בניה מה יש לך לומר	5
6. ת. לצורך היתר בניה לא התחייבתי לשנות את תוואי הגדר הוא ידע בדיוק על מה הוא חותם.	6
7. ש. במשך השנים עד החודשים האחרונים שקדמו להגשת התביעה באו אליך השכנים בטענה שמגיע להם אדמה.	7
8. ת. לא.	8
---	12
9. ש. כדי שעסיה יחתום על הבקשה אמר שאתה חייב לו אדמה וגם אמרת אם היה מבקש עוד מטר היית מסכים	13
10. ת. כי לא העסיק אותי הגודל של השטח.	14
11. ש. אתה אומר שהיום גודל השטח מעסיק אותך.	15
12. ת. היום הבית שלי במצב מוגמר יש גדר וצמחיה לבוא אחרי 10 שנים שחתם לי.	16
13. ש. אם ראית אז שאתה מחזיק 50 מטר יותר יכול להיות שבגלל זה לא הפריע לך שהוא מקבל שטח.	17
14. ת. לא ידעתי" (ר' פרוטוקול הדיון מיום 19.10.09 בעמ' 8-11).	18
---	21
15. 20. מהראיות שהוצגו בפני נראה, כי גדר הרשת היתה בצורת "ריש" (ר' ת/3).	22
16. בין אם ביוזמתם של התובעים ובין אם לאו יושר תוואי הגדר.	23
17. התוואי החדש מצא ביטוי בבקשה מס' 20000322 למתן היתר הבניה- ת/1 שהוגשה ע"י הנתבע ואשר על הבקשה חתומים התובעים שניהם הגב' עסיה דינה ומר עסיה אליהו.	24
---	26
---	27
18. 21. התובעים טענו בהקשר זה כאמור, כי חתימתם הינה הסכמה לבניה ברכוש המשותף ולא הסכמה לתוואי הגדר או לבנייתה, הואיל ואלה לא היו חלק מן הבקשה כלל.	28
19. לטענתם, הגדר מסומנת בבקשה כגדר רשת קיימת, ותוואי הגדר אינו יכול להיות מוחזק כמוסכם על התובעים, כל עוד אינו משקף חלוקה של המגרש לשני חלקים שווים.	29
---	30
---	31
---	32
---	33

22. הנתבע טען, כי בכתב ההגנה, מאשרים התובעים באופן שאינו משתמע לשתי פנים, כי "ויתרו" על חלק מהרכוש המשותף לטובת הנתבע. לטענתם התובעים ידעו את גודלו של שטח חצרם ביחס לשטח חצרו של הנתבע במשך שנים רבות וטרם הגשת התביעה במחוזי, והויתור נעשה בהסכמתם ומרצונם החופשי.
23. התובעים המתגוררים כאמור 48 שנים בדירה היו שותפים מלאים לקביעת תוואי הגדר לאורך השנים. הם הסכימו להסדר הקיים ואף נהנו ממנו בפועל בדמות שימוש יחודי בחצר הבית המשותף שמצד מזרח.
- גם כיום הם נוהגים בחצר זו כבקנין פרטי, גידרו את החצר, הציבו בה מתקנים שונים וקירו חלקים ממנה בפרגולה ואיש אינו רשאי להיכנס אל החצר ללא הסכמתם.
- אין ספק, כי לו ביקש הנתבע לבנות מבנה כלשהו בחצר זו, היו התובעים מתנגדים נחרצות.
24. זאת ועוד, לתובעים ניתנה לכאורה הזדמנות לעמוד על זכויותהם עם חילופי הבעלות בדירה הצמודה. משמכר מליחי את זכויותיו לחיים, הנתבע, היו זכאים התובעים להרהר בשנית בהיקף ההרשאה שניתנה על ידם עד אז שכן ההסכמה שניתנה אינה כובלת צד שלישי לה. ואולם, התובעים בחרו ליתן הרשאה חדשה לנתבע לעשות שימוש בתוואי מתוקן, תוואי שבין אם ביוזמתם ממש ובין אם בהעדר התנגדות מוחלטת נבנתה ע"י הנתבע. הם אף אישרו בחתימת ידם את הבקשה לבניה שהוגשה ע"י הנתבע על תוואי הגדר המצוין בה.
25. נראה כי מדובר איפוא בחלוקה מוסכמת מזה שנים. התמשכות ההסדר אף אך משנת 2000 יצרה ציפייה לגיטימית כי אותו הסדר יעמוד בין הצדדים אף מכאן ולהבא. אגב ההסדר ניתנו תמורות שכן כל צד קיבל חלק מסוים בחצר לשימוש ייחודי, תוך התחייבות מובנת מאליה להימנע משימוש בחצר של האחר.
- התובעים עצמם יזמו או הסכימו כאמור תיקון תוואי הגדר ושתיקתם לאורך כעשור מלמדת כאלף עדים על הסכמה זו.
- הנתבע אכן הסתמך על הסכמה זו ושינה מצבו לרעה, הוא בנה את הגדר בלא מחאה כאמור, פנה בבקשה לקבלת היתר בניה, השקיע כספים ומאמצים בהכנת אותה תכנית וביישומה והתובעים לא נקטו בכל פעולה שיש בה ללמד כאמור על התנגדות לחלוקה.
- לאור האמור נוצרה לתובעים מניעות מן הצדק לחזור בהם מההסכמה הן לשימוש של הנתבע במקרקעין המשותפים והן לשימוש שלהם עצמם.

1. בהקשר זה, הגנה על זכות הקניין צריכה להיעשות בכפוף לעקרון תום הלב וההגינות
בכל הנוגע להפעלת אותה זכות. עקרונות אלה נלמדים הן מן הדין הכללי היינו סעיף
39 לחוק החוזים והן מכוח הוראת החוק הפרטיקולרית כגון הוראת סעיף 14 לחוק
המקרקעין הקובע כי: "בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי
להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר".
תום לב, כך נפסק, "מבקש למנוע הפעלת הזכות מתוך התעלמות מקיומו של הצד
האחר ובהתעלם מהאינטרס החברתי.

- עקרון תום-הלב קובע רמת התנהגות של אנשים הדואגים, כל אחד לאינטרס שלו
עצמו. עקרון תום-הלב קובע כי השמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת
ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר. אדם לאדם -
לא זאב, ולא מלאך; אדם לאדם - אדם" (פרשת רוקר, בעמ' 279). (ר' עא 97/2643
שלמה גנז נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ נז (2) 385, עמוד 402-400) ".
26. עקרון תום הלב אינו יכול, ממילא, לסייע לטענות התובעים, שכן העובדה כי שתפו
פעולה עם תיקון הגבול או אף העלימו עינם מבניית הגדר באותו תוואי, שלא נעשתה
באישון לילה ולא ביום אחד, ולמעשה עד להגשת התביעה בבית המשפט המחוזי
כמתואר.
27. אשר לתביעה לתשלום חלקם של הנתבעים שכנגד בבניית הגדר - מרכיבי התביעה
שכנגד לא הוכחו בנסיבות המקרה, לא הוצגו כל ראיות אף לעלות הגדר ודי בכך כדי
לדחות מרכיב זה של התביעה. במשקל הראיות בתיק, לא מן הנמנע, כי עלות הגדר
ככל שישנה מהווה ראיה נוספת למתן התמורה בגין ההסכמה האמורה, שאף היא
מצטרפת לטענת ההסתמכות מכוחה, כאמור לעיל.
28. מכל האמור אני דוחה את התביעה העיקרית על כל מרכיביה. לאור האמור אני דוחה
אף את התביעה הכספית נשוא כתב התביעה שכנגד.
29. אכן נמלכתי בדעתי בשאלת הוצאות שתי התביעות, אין ספק, כי עיקרן של ההוצאות
הן מכוחו של ניהול ההליך בתביעה העיקרית. התביעה שכנגד הוגשה אף ככתב
הגנה+תביעה שכנגד. כידוע על פי תקנות 511 ו-512 לתקנות סדר הדין האזרחי,
התשמ"ד-1984, נתונה קביעת סכום ההוצאות לשיקול דעתו של בית המשפט.
במסגרת שיקוליו לעניין החיוב בהוצאות, על בית המשפט להתחשב, בין היתר, בשווי
הסעד המבוקש, בדרך ניהול המשפט, בכמות ובמהות העבודה שהושקעה ובנסיבות
אחרות שיש בהן כדי להשפיע על גובה ההוצאות הנפסקות. כן נקבע בפסיקה, כי

בהעדר נסיבות מיוחדות, אין צידוק לכך שבעל דין שזכה במשפט ייצא בחסרון כיס	1
וישא בעצמו אפילו מקצת ההוצאות שנאלץ להוציאן (ראה ע"א 77/85 חברת	2
החשמל מחוז ירושלים נ' חברת החשמל לישראל פ"ד לט(2) 592.	3
במקרה דנן, שתי ישיבות קוימו בתיק והצדדים העידו בעצמם.	4
עיקר ההליך נסוב סביב התביעה העיקרית משנדחתה זו ולאחר שהתחשבתי בכך	5
שאף התביעה שכנגד נדחתה כאמור ולמען קידומו של שלום בית בין הצדדים אני	6
מחייבת את התובעים, הנתבעים שכנגד, לשלם לנתבע, התובע שכנגד סך של 2500 ₪	7
בגין הוצאות משפט, לרבות שכר טרחת עורך דין.	8
	9
ניתן היום י"ד אייר תש"ע, 28 אפריל 2010, בהעדר הצדדים.	10
	11
	12
	13
טלי להב	14
המפקחת על רישום המקרקעין	15
פתח תקוה	16
	17
	18